

1500845-30.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... das elementares do delito de tráfico de substância entorpecente praticado pelo acusado, inexistindo dúvida quanto à autoria.

A materialidade delitiva está demonstrada no auto de exibição e apreensão a págs.15/16 (sacola, droga e anotações da contabilidade do tráfico); nos laudos de constatação (págs.19/21 e reproduzido às págs. 86/88), químico-toxicológico (págs.89/91) e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500845-30.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500845-30.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2113678/2022 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 24568430 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2113678 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS GOMES HEREMITA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

LUCAS GOMES HEREMITA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de abril de 2022, por volta das 05h20min, na Estrada Galvão Bueno, altura do nº 11.739, bairro

Batistini, nesta Comarca de São Bernardo do Campo, guardava e trazia consigo drogas consistentes em 122g de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como maconha, acondicionadas em 58 invólucros plásticos; 54,87g de cocaína, acondicionadas em 179 eppendorfs; e 13,01g de cocaína na forma de crack, acondicionadas em 42 invólucros plásticos, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de págs. 15/16 e laudos de constatação de págs. 19/21 e químico-toxicológico às págs.89/91.

Segundo o apurado, na data e local acima indicados, o acusado guardava e trazia consigo duzentas e setenta e nove (279) embalagens individuais de drogas para entrega a consumo de terceiros.

É dos autos que guardas municipais foram acionados para averiguação de ocorrência de arrastão no local dos fatos. Ali chegando, não constatarem a prática de qualquer crime patrimonial, mas avistaram o réu próximo a um ponto de ônibus e decidiram por sua abordagem.

LUCAS passou a correr em fuga assim que notou a aproximação dos GCMs, arremessou uma sacola plástica ao chão e pulou em uma ribanceira na tentativa de se furtar à abordagem, mas logo foi detido.

Os guardas municipais recuperaram a sacola que o acusado havia dispensado, e no interior dela encontraram 179 eppendorfs contendo cocaína, 42 invólucros plásticos com crack e 58 porções de maconha, além de anotações relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas.

Indagado, o acusado confessou informalmente aos guardas civis a prática do crime. Nestas circunstâncias, ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

A quantidade e diversidade das drogas apreendidas, a sua forma de acondicionamento, a apreensão de anotações com contabilidade, bem como as circunstâncias nas quais se deu a prisão em flagrante revelam a prática do tráfico de entorpecentes.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial a págs. 04/32. Notificado (pág.99), o acusado ofertou defesa preliminar (pág.102). Recebida a denúncia (págs.110/111), o réu foi citado (pág.116). Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, interrogando-se o réu.

Em debates, o Ministério Público requer a condenação do réu nos termos da denúncia, com elevação da pena e fixação de regime inicial fechado, reconhecida a reincidência; ao passo que a defesa postula pela absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares do delito de tráfico de substância entorpecente praticado pelo acusado, inexistindo dúvida quanto à autoria.

A materialidade delitiva está demonstrada no auto de exibição e apreensão a págs.15/16 (sacola, droga e anotações da contabilidade do tráfico); nos laudos de constatação (págs.19/21 e reproduzido às págs. 86/88), químico-toxicológico (págs.89/91) e pericial de págs. 92/93 (anotações contábeis).

Quanto à autoria, após a opção pelo silêncio na fase policial (pág.09), em Juízo o acusado negou a prática do delito:

Vivia na rua havia um ano, após ter brigado com a família e todos os dias, cedo, se dirigia a uma padaria próxima do ponto de ônibus mencionado nos autos para receber pão. Aguardava no local a abertura do estabelecimento quando foi abordado pelos guardas civis municipais, que exigiram a entrega da 'peça' (arma) e de bens roubados, agredindo-o em quadra existente na praça situada nas imediações. Não praticou crime patrimonial e não entregando o que exigia os agentes da lei, foi falsamente incriminado por eles, que lhe imputaram a prática de tráfico de droga. A negativa de autoria ficou isolada nos autos pelo mais da prova colhida em instrução.

Sob o crivo do contraditório, nos depoimentos dos guardas civis municipais Lucas Alves dos Santos e Cristiano Olavo Cantele dos Santos, que em relato coeso e harmônico com o anterior, informaram os passos da diligência encetada na data do

fato e espancaram qualquer dúvida acerca da existência do crime:

Foram acionados para averiguação de ocorrência de arrastão no local dos fatos. Ali há uma praça pública, com parque e quadra, bem iluminada, e um ponto de ônibus próximo. Quando passavam devagar com a viatura, visualizaram o acusado ali parado e sozinho. Não havia pessoas próximas dele. Quando notou a presença da equipe, o réu saiu correndo e dispensou a sacola plástica que portava no trajeto. Foi perseguido sem que o perdessem de vista.

Ele pulou em uma ribanceira na tentativa de se furtar à abordagem, mas logo foi detido (o réu foi detido porque, ao pular, caiu sobre as pedras e foi socorrido à UPA).

Detido e recuperada a sacola, dentro dela localizaram porções de maconha, cocaína e crack em quantidade típica da mercancia ilícita, além de folha com anotação típica da mercancia ilícita.

Inquirido, o agente confessou informalmente o tráfico de droga. Disse que havia acabado de receber a substância entorpecente para a venda.

Não conheciam o acusado antes da abordagem.

O réu apresentou, no local da abordagem, o nome do irmão, fato descoberto na Delegacia de Polícia.

O guarda civil municipal não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.1996 - p. 39.846).

Os depoimentos dos guardas devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas (RDTJRJ 7/287).

Não se pode recusar eficácia probante aos testigos da testemunha que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

As lesões corporais verificada nos autos não afastam a versão dos guardas civis, no sentido de que o réu pulou ribanceira e se machucou, ao fugir, tendo sido socorrido.

Não conheciam o acusado, assertiva acusatória não impugnada nos autos. Inexiste o mínimo indício de que os guardas municipais tivessem qualquer motivo para colocar em risco as suas carreiras forjando uma situação prejudicial ao réu, que sequer conheciam, imputando-lhe falsamente crime.

Nesta linha:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (TJSP, rel. Osni Pereira, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16ª Câ. Crim., julgado em 27/01/2015).

A ausência de qualificação de civis como testemunhas, por si só, não leva à absolvição da agente, diante da conhecida dificuldade de tal diligência em crimes da natureza do ora tratado (hora do crime, geografia do local, 'lei do silêncio', dentre outros fatores).

Certo é que, além da harmônica prova oral acusatória, a variedade e a espécie de substância entorpecente apreendida (179 eppendorfs contendo cocaína, 42 invólucros plásticos com crack, e 58 porções de maconha), a forma como acondicionada (individualmente) e as circunstâncias da prisão tornam evidente que a droga se destinava ao consumo de terceiro.

Tais circunstâncias constituem elementos relevantes para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, conforme preconiza o artigo 28, §2º, do

citado Diploma.

Consigne-se que, embora o réu não tenha sido preso enquanto efetuava a venda da droga apreendida, tal circunstância, por si só, não afasta a imputação feita na denúncia.

Isso porque o crime de tráfico, como delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, consoma-se com a ocorrência de qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, dentre as quais se insere aquela imputada ao acusado na denúncia, sendo suficiente a identificação da finalidade mercantil.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico de droga pelo réu.

Não militam quaisquer excludentes de ilicitude ou dirimentes em benefício do acusado, ausente prova nesse sentido.

Portanto, o acusado realizou conduta típica, antijurídica (art. 33, caput, a Lei nº 11.343/06) e, em face de sua culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Analisados os fatores de individualização da pena, verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis ao acusado. São desfavoráveis as suas condições subjetivas. O réu ostenta condenação anterior e irrecorrível pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0013791-24.2012 - 3ª Vara Criminal de Diadema. Trânsito em julgado em 2013. A pena foi extinta pelo cumprimento em 2014, cf. certidão criminal às págs. 40/42).

Outrossim, a quantidade de droga apreendida em poder do réu (279 porções individuais), de natureza diversa (maconha, cocaína e crack) torna a sua conduta mais censurável, mormente em relação à cocaína, que na forma de pó ou pedra tem alto potencial ofensivo, gerando maior probabilidade de provocar dependência química, de forma a atingir com mais vigor a saúde pública, bem jurídico protegido pelo legislador.

O quantum de droga apreendido demonstra o devastador resultado que a conduta do increpado provocou no meio social. O crime é de perigo abstrato.

Sobressai-se, no fato em tela, maior grau de censurabilidade na conduta do agente, que não se manteve apenas nos moldes inerentes ao tipo penal em espécie, nos exatos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Relevante esclarecer que o Col. Supremo Tribunal Federal, inclusive, exarou o entendimento de que a "natureza" (ou "qualidade") e quantidade do entorpecente destinado à comercialização configura critério hábil para a exasperação da pena dos traficantes ("HC 94655/MS MATO GROSSO DO SUL, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 19/08/2008, Primeira Turma).

O legislador brasileiro, ao instituir a norma do artigo 42, da Lei 11.343/06, impôs aos juízes o dever de ponderar, no momento da fixação das penas dos delitos previstos nessa lei especial, "a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente", e isto com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal".

Assim, diante do acima ponderado, elevo a reprimenda em 1/6, índice proporcional às condições subjetivas do agente, circunstâncias e consequências do delito, o que perfaz 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

A seguir, verifica-se a agravante da reincidência (autos nº 0000333-34.2016 - por crime de tráfico de droga. Tramitou a 2ª Vara Criminal de Diadema. Trânsito em julgado em 2017. Réu ainda cumpria pena em regime aberto desde 26/04/2021, cf. certidão criminal às págs. 40/42), razão pela qual elevo a reprimenda em 1/6, o que perfaz 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa. Não há atenuantes a considerar.

O reconhecimento de antecedentes criminais na primeira e da reincidência na segunda etapa da dosimetria não configura bis in idem, pois foram consideradas condenações distintas em cada etapa.

Neste sentido:

"Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a existência de condenações anteriores transitadas em julgado pode justificar validamente a elevação da pena-base, tanto como maus antecedentes, bem como conduta social e personalidade, desde que diferentes as condenações consideradas, sob pena de bis in idem. O que não se

admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial ou de uma circunstância judicial e da reincidência (HC n. 348.451/RJ, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/5/2016)" (AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/6/2018, DJe 2/8/2018)" (AgRg no RESp 1816050/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/09/2019).

Não incidem causas de aumento de pena. Não se aplica a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, não preenchidos os predicados legais. O RÉU É REINCIDENTE específico e ostenta antecedentes criminais (outra condenação pelo crime de tráfico de droga).

O valor de cada dia-multa será calculado no valor unitário mínimo e atualizado desde a data da infração.

O regime para o início de cumprimento de pena é o fechado. Mostra-se adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a gravidade CONCRETA do delito de tráfico, circunstâncias em que foi praticado e suas consequências, que demonstram a periculosidade e ousadia do agente, aptas a reclamar reação severa, proporcional e seguramente eficaz, sob pena de impunidade.

Inexiste relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. O acusado é reincidente específico (autos nº 0000333-34.2016 - por crime de tráfico de droga. Tramitou a 2ª Vara Criminal de Diadema. Trânsito em julgado em 2017) e possui condenação anterior e irrecorrível por tráfico de drogas (autos nº 0013791-24.2012 - 3ª Vara Criminal de Diadema. Trânsito em julgado em 2013. A pena foi extinta pelo cumprimento em 2014). Ainda cumpria pena anterior e definitiva por tráfico de droga, em regime aberto, quando voltou a delinquir, cf. certidão criminal juntada às págs. 40/42. O acusado faz da hedionda mercancia ilícita o seu meio de vida, não se tratando, o fato em tela, de mero descuido na vida do acusado.

Nesse passo, regime mais benéfico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou aplicação do "sursis", a par de não preenchidos os requisitos subjetivos dos artigos 33, §3º, 44 e 77, ambos do Código Penal, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena e constituiria incentivo à reiteração da conduta.

Resultaria ilógica, nesta situação, a aplicação de tais benesses, sob pena de esvaziar-se o tratamento rígido que a Lei buscou propiciar a fim de concretizar a política criminal voltada a dirimir a traficância de entorpecentes (afastado o tráfico privilegiado), que, a propósito, envolve sempre outras práticas delitivas execráveis que tanto devastam o país.

Não se olvida que a Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, permitindo ao Juiz o desconto, na sentença, do tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação no total de pena imposta.

Ocorre que referida alteração apenas tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência, o que não se vê patenteado no caso em tela.

Ainda que se entenda que o tempo de prisão processual deva ser descontado para a aplicação do artigo 33, §2º, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em razão do quantum, mas pelas desfavoráveis condições subjetivas apresentadas pelo acusado e pela quantidade de droga apta a demonstrar periculosidade diferenciada, que tornam mais reprovável a conduta criminosa, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal.

Há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a modalidade mais gravosa.

Acerca do assunto, merece destaque o seguinte julgado emanado do E. TJSP, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a detração:

"É inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Deve o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a

embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria" (TJSP - 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 - Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão no Juízo da Execução.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o acusado LUCAS GOMES HEREMITA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelas razões expostas alhures.

O réu respondeu ao processo preso (convertida a prisão em flagrante em preventiva - págs.45/48).

Em que pese a excepcionalidade da custódia cautelar, a medida ainda é necessária para o atendimento da finalidade da persecução penal.

Presente o *fumus comissi delicti*, consubstanciado nas declarações dos guardas civis municipais e na presente condenação. O *periculum libertatis* evidencia-se na gravidade CONCRETA da conduta imputada ao acusado e nas desfavoráveis condições subjetivas que apresenta, a demonstrar a ineficácia das medidas cautelares para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Não se trata de presunção genérica de periculosidade de indivíduo assim acusado.

Cuida-se de constatação cotidiana, reforçada pelo legislador pátrio: O tráfico de drogas é atividade que denota a criminalidade organizada; a disseminação das drogas impõe aos usuários a prática de delitos antecedentes, contra o patrimônio alheio, para sua aquisição, e de delitos posteriores, geralmente contra pessoas, em razão da alteração do estado psíquico decorrente de seu consumo.

O acusado ostenta duas condenações anteriores e irrecorríveis justamente pelo delito de tráfico de droga. É reincidente específico. Ainda cumpria a pena anterior em regime aberto quando voltou a delinquir. Não há dúvida de que adota a prática da mercancia ilícita como meio de vida.

Há fortes indícios de que, em liberdade, voltará a delinquir.

Não se cuida, na espécie, de apenas um desvio na vida do réu, que assim ostenta periculosidade acentuada e diferenciada, bem como conduta social avessas aos preceitos que presidem a convivência em comunidade.

As medidas cautelares previstas na legislação processual penal não se mostram, portanto, adequadas e suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo imprescindível para eficácia da persecução penal a manutenção da custódia cautelar.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o réu não poderá apelar em liberdade. Expeça-se o necessário e recomende-se o acusado na prisão onde se encontra recolhido.

Em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Inexiste prejuízo aos sentenciados quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019) e não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência.

Considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar nesta sentença, há inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019).

Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

De plano, não impugnados os laudos periciais:

a) e não tendo havido controvérsia sobre a natureza ou quantidade da substância ou

do produto, bem como sobre a regularidade do respectivo laudo químico-toxicológico, oficie-se à Autoridade Policial para destruição das substâncias entorpecentes apreendidas nos autos;

b) autorizo a destruição da sacola (oficie-se à autoridade competente) e da folha contendo anotações típicas da contabilidade da mercancia ilícita. Oportunamente, comunique-se Distribuidor e IIRGD.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se guia de recolhimento definitiva;

b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;

Custas pelo réu no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03. A exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA